Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent11vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5193644-52.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: IVAN AMARAL PINHO

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de ação condenatória proposta por **IVAN AMARAL PINHO** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** relatando que foi diagnosticado com câncer de próstata (CID-10 C61), em estágio IV (avançado), com atingimento da bexiga, linfonodos, com metástases ósseas. Disse que, antes do diagnóstico, no final de junho/2023, submeteu-se a exames para o diagnóstico de câncer, custeando, de forma particular, o exame PET CT, no valor de R$ 4.351,00. Contou que, após o diagnóstico, houve demora no fornecimento de resposta à requisição de tratamento via ZOLADEX (gosserelina) 10.8 mg a cada 90 dias, combinado com ZYTIGA (abiraterona) 1000mg diárias e Prednisona 10mg e que por isso custeou o tratamento perante o Hospital Santa Casa, de forma particular, em 01/09/2023, pelo valor de R$ 12.769,85, pois havia possibilidade de perda da função renal pela obstrução dos ureteres, bem como pelo agravamento das dores por metástases ósseas. Descobriu, posteriormente ao diagnóstico e requisição do tratamento prescrito pelo médico, a negativa da solicitação aos medicamentos ZYTIGA (abiraterona) 1000mg diárias e Prednisona 10mg diária, com custo mensal de R$ 11.684,42. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e que o caráter não regulamentado do contrato não constitui óbice ao reconhecimento do direito de cobertura contratual. Em sede de tutela de urgência, requereu que a ré seja compelida a fornecer os medicamentos ZOLADEX (gosserelina) 10.8 mg a cada 90 dias, combinado com ZYTIGA (abiraterona) 1000mg diárias e Prednisona 10mg, conforme prescrição do médico. Como pedido final, requereu a confirmação da tutela provisória, tornando definitiva a obrigatoriedade de cobertura aos medicamentos, e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.351,00 e R$ 12.769,85, a título de exames e medicamentos custeados de forma particular, além de eventuais prejuízos suportados até o acesso ao tratamento pelo plano. Por fim, pediu a concessão da AJG e juntou documentos.

Concedida a liminar para determinar o fornecimento de cobertura dos medicamentos Zytiga (abiraterona) 1.000 mg e Prednisona 10 mg, conforme o laudo médico anexado ao evento 1, RECEIT19, sob pena de multa.

Após juntada de documentos, foi indeferida a AJG.

Juntado o retorno positivo do mandado de intimação pessoal.

O autor interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento.

Devidamente citada, a requerida ofereceu contestação. Sustentou que o contrato é não regulamentado, sendo inaplicáveis as disposições da Lei dos planos de saúde. Defendeu a existência de cláusula contratual que veda expressamente o custeio do tratamento, citando a cláusula décima quarta. Aduziu que há um parecer técnico n. 45, emitido pela ANS, indicando que "para os "planos antigos" não adaptados (planos contratados até 1/1/1999 e não ajustados à Lei nº 9.656, de 1998, nos termos de seu art. 35), as coberturas obrigatórias a serem garantidas são as que constam das cláusulas contratuais acordadas entre as partes". Destacou entendimento da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, por meio do Enunciado n. 33. Impugnou o pedido de danos materiais, justificando na ausência de cobertura contratual. Postulou pela improcedência do pedido.

Houve réplica.

Em decisão saneadora, foi registrada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Instadas sobre o interesse na produção de provas, as partes pediram o julgamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A solução da demanda independe de outras provas, incidindo, por consequência, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Afigura-se, pois, dispensável a dilação probatória, sendo, ademais, medida que atende aos princípios de economia processual e da celeridade da justiça.

Cuida-se de ação pela qual o autor objetiva a condenação da ré a fornecer o medicamento ZOLADEX (gosserelina), ZYTIGA (abiraterona) e PREDNISONA, conforme prescrição médica, no tratamento de neoplasia maligna de próstata (CID-10 C61), além do reembolso de valores despendidos com o custeio de exame e medicamento na modalidade particular, em face de negativa indevida do plano, no valor de R$ 4.351,00 e R$ 12.769,85.

Em suas razões, a ré defende a falta de cobertura no plano de saúde, por se tratar de contrato não regulamentado, sem previsão para medicamento de uso oral nas cláusulas contratuais.

Nessa linha, inegável a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios que norteiam as relações de consumo, disposições que devem ser aplicadas em conjunto com o regramento especial dos plano de saúde (Lei n° 9.656/98).

A autora é cliente dos serviços prestados pela ré, enquadrando-se no conceito de consumidor, nos moldes do artigo 2.º da Lei nº 8.078/90. A parte ré, por seu turno, na condição de prestadora de serviços, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3.º, do mesmo diploma legal.

Aliás, tal questão restou sedimentada, a partir da edição da Súmula 608/STJ, que assim dirimiu a controvérsia:

> ***"Súmula 608:*** *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*

No caso em tela, é incontroversa a relação jurídica mantida entre as partes através de plano de saúde coletivo por adesão, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, vigente desde meados de 1990 (evento 28.3), sendo, portanto, anterior às disposições da Lei n° 9.656/98.

Nesse cenário, de acordo com o entendimento firmado pelo STF na ADI n° 1.931, as disposições da Lei n° 9.656/98 não se aplicam aos contratos de plano de saúde firmados anteriormente a sua vigência, em prestígio ao princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

De amparo, destaco o seguinte trecho da decisão em comento, *verbis:*

> *"As empresas operadoras de planos de saúde, constituídas anteriormente às regras estabelecidas nas duas normas questionadas nesta ação, já atuavam no mercado como prestadoras de serviços de assistência à saúde e, por isso mesmo, ainda que não regulamentadas especificamente suas atividades, funcionavam aos olhos da Administração Pública na forma da legislação civil.*
>
> *(...)*
>
> *Assim sendo, os contratos assinados com os consumidores antes da nova legislação não podem ser modificados pelas regras ora impostas, sob pena de violação ao princípio do direito adquirido e também ao ato jurídico perfeito - garantias protegidas pelo mandamento constitucional."*

Trata-se, portanto, do chamado *contrato não regulamentado*.

Assim, as coberturas devidas pela denunciada regem-se pelos termos do contrato, pelo ordenamento geral de direito civil e, em especial, pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente frente a seu caráter de norma principiológica, de ordem pública e amparo constitucional não só como direito fundamental (artigo 5°, inciso XXXII, da CF), mas também como princípio da ordem econômica (artigo 170, inciso V, da CF).

<u>Ainda assim, o pedido da parte autora merece prosperar.</u>

Veja-se que a controvérsia reside na possibilidade de compelir o plano a custear medicamentos e exames para o tratamento de neoplasia maligna de próstata, sendo ambos os pedidos negados administrativamente (evento 1.15 e 1.16).

Sobre o tema, a cláusula décima quarta, inciso III, exclui a cobertura de "*tratamento especializado de qualquer natureza, tais como psicoterapia, **quimioterapia**, cineangiocoronariográfica com cateterismo, tomografia computadorizada, cintilografia, ressonância magnética e outros exames oferecidos corriqueiramente na data de firmatura deste contrato (...).*[1]" *(grifei)*

Entretanto, entende-se que a aplicação de tal cláusula deve ser vista com ponderação.

Primeiramente, deve-se deixar claro que, apesar de posterior ao contrato, a relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor e dos princípios que norteiam as relações de consumo.

Cabe lembrar que, nesse sistema, os contratos passaram a ser vistos não somente como instrumento jurídico às relações econômicas, mas também como mecanismo de proteção do interesse das partes. Se de um lado a função social dos contratos ganhou *status* de princípio, de outro, a liberdade contratual e a força obrigatória dos contratos foram relativizadas, devendo, as condutas dos contratantes, estarem pautadas no "princípio da boa-fé objetiva", também chamado de "princípio da confiança", bem como em todos os deveres anexos ou acessórios desta relação negocial, quais sejam: a segurança, a informação, a lealdade e a cooperação.

Portanto, entende-se que o fato de o contrato não estar adaptado à nova lei não autoriza, consequentemente, que possa não estar adaptado a sua função social, que é princípio regente do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, é sinalizado pela doutrina que "*a função social constitui princípio contratual de ordem pública - conforme consta do art. 2.035, parágrafo único, do Código Civil -, pelo qual o contrato deve ser, necessariamente, interpretado e visualizado de acordo com o contexto da sociedade.*"(in TARTUCE, Flávio e NEVES, Daniel Amorim de Assunção. Manual de direito do consumidor (...) 9.ed - 2020, p. 46/47)

Dito isso, para a interpretação do caso concreto, impõe-se considerar a nítida prevalência do direito fundamental à saúde e a dignidade do paciente em detrimento da autonomia privada e dos limites contratuais.

Não é por outra razão que a posição atual da jurisprudência é no sentido de garantir o acesso amplo a tratamentos antineoplásicos, dispensada a investigação acerca de limitações contratuais, como previsão no rol da ANS e seu caráter *off label.*

Corroborando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. RECUSA INDEVIDA. SAÚDE DA PACIENTE. PRECARIEDADE. AGRAVAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
3. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.
5. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.
6. Existem casos em que há dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.
7. Na hipótese, o acórdão recorrido ressaltou haver previsão contratual para a cobertura do procedimento e a precariedade e possibilidade de agravamento do quadro clínico da paciente. Assim, constata-se a inexistência de dúvida jurídica razoável e resta caracterizado o abalo moral decorrente da recusa indevida que enseja indenização.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.098.737/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)(grifei)

Também é fundamental contextualizar que o câncer é a segunda doença mais letal do país, segundo estudo do Observatório nacional de Oncologia e Instituto Nacional do Câncer[2], trilhando o caminho da liderança nos próximos anos, e constituindo uma das principais chagas da sociedade contemporânea, o que nos leva a questionar a real função do plano de saúde cujo rol de cobertura não fornece exames ou medicamentos ao paciente em estado de vulnerabilidade pelo câncer. Ademais, o plano do requerente possui segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, configurando, portanto, modalidade relativamente completa da linha de produtos.

A partir disso, entende-se que a cláusula que limita o acesso do paciente a exames e medicamentos para o tratamento de carcinomas coloca o consumidor em desvantagem exagerada ao tolher direito inerente à relação jurídica de plano de saúde, conforme parâmetros extraídos de sua função na atual conjuntura social.

Desse modo, não merece prosperar cláusula restritiva a direito inerente a natureza do negócio, visto que abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, e § 1.°, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor, que assim determina:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso."

Nesse sentido é a jurisprudência, ainda que se trate de contrato não regulamentado:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CÂNCER DE RIM. MEDICAMENTO AXITINIBE. USO DOMICILIAR. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA NO TOCANTE AO PLEITO DE REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS INVOCADOS PELAS PARTES. JULGAMENTO NOS LIMITES DO PEDIDO, APENAS COM ANÁLISE SOB ENFOQUE DIVERSO DO PRETENDIDO PELA AUTORA, CONSIDERANDO CLÁUSULA CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL ACOSTADO COM A INICIAL. 2. AINDA QUE INAPLICÁVEL A LEI 9.656/98 AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE FIRMADOS EM DATA ANTERIOR, A QUESTÃO DEVE SER APRECIADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608 DO STJ), COM INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES CONFORME (ART. 47 DO CDC). ***3. NOS TERMOS DO ART. 51, IV, DO CDC, MOSTRA-SE ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI DO TRATAMENTO O FÁRMACO PLEITEADO, UMA VEZ QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA FRENTE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 4****. HIPÓTESE EM QUE O INÍCIO DO TRATAMENTO FOI INTEGRALMENTE CUSTEADO PELA OPERADORA E O CONTRATO FOI ADAPTADO ÀS DISPOSIÇÕES DA LPS NO CURSO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR EM TER O TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE*

INTEGRALMENTE CUSTEADO PELA SEGURADORA. 5. ALÉM DISSO, O MEDICAMENTO AXITINIBE ESTÁ ELENCADO NO ROL DA ANS COMO COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO RIM, BEM COMO HÁ NOTAS TÉCNICAS DO E-NATJUS NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E EFICÁCIA DO FÁRMACO PARA O CASO EM TELA. 6. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O DEVER DE REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA PARTE AUTORA NA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. 7. O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO DÁ ENSEJO AO RECONHECIMENTO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. HIPÓTESE EM QUE A NEGATIVA DE COBERTURA, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL, HAJA VISTA QUE ESTAVA CALCADA EM EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL (DÚVIDA RAZOÁVEL). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50012302420188213001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-09-2023)(grifei)

Em face disso, fixa-se como indevida a negativa administrativa do exame PET CT e medicamentos antineoplásicos (ZOLADEX (gosserelina), ZYTIGA (abiraterona) e PREDNISONA).

E verificado o descumprimento do contrato, surge para a parte autora o direito de restituição pelos valores desembolsados para o tratamento de câncer na modalidade particular, nos termos do artigo 389 do Código Civil.

Com esse posicionamento, destaco:

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. São aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes, na medida em que se trata de relação de consumo (Súmula 608 do STJ). Os planos de saúde devem se cingir às enfermidades que dão ou não cobertura, descabendo a eles a limitação aos procedimentos e tratamentos, cuja prescrição é de cunho exclusivo do médico assistente dos segurados. A cobertura da cirurgia de urgência indicada pelo médico assistente do consumidor para remoção do expansor, na região onde foi retirada a mama direita da autora, em razão da moléstia de **câncer**, é devida, sendo de direito a restituição dos valores despendidos pela parte autora. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70079671608, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 29-08-2019)*

Nesse aspecto, cabível a condenação da ré ao reembolso das despesas suportadas pela parte autora, regularmente comprovadas nos eventos 1.20 e 1.21, no valor de R$ 4.351,00 e R$ 12.769,85. A quantia deve sofrer correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso e ser acrescida juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, de acordo com o postulado e não impugnado.

Nessa conjuntura, a procedência do pedido é medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo ***PROCEDENTES*** os pedidos formulados por **IVAN AMARAL PINHO** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** para:

A) CONFIRMAR a tutela provisória e **DETERMINAR** à ré que forneça à parte autora a cobertura dos medicamentos ZOLADEX (gosserelina), ZYTIGA (abiraterona) e PREDNISONA, conforme o laudo médico;

B) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.351,00 e R$ 12.769,85, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador do autor, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da condenação contida no item 'b', nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

Havendo interposição de apelação no prazo recursal, intime-se o apelado, para, querendo, oferecer contrarrazões. Após, nada mais ensejando intervenção do juízo de primeiro grau, remeta-se ao TJRS. Do mesmo modo, na hipótese de interposição de apelação adesiva, vista à parte contrária para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, sendo, após, remetido ao TJRS.

Não havendo interposição de recurso certifique-se o trânsito em julgado e, uma vez recolhidas eventuais custas, arquive-se com baixa.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **CINTIA DOSSIN BIGOLIN, Juíza de Direito**, em 19/6/2024, às 17:32:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10060860167v38** e o código CRC **02a987f9**.

---

1. "Cláusula 14: A contratada não se responsabiliza, em hipótese alguma, pela cobertura ou prestação dos seguintes serviços: (...) III – tratamento especializado de qualquer natureza, tais como psicoterapia, quimioterapia, cineangiocoronariográfica com cateterismo, tomografia computadorizada, cintilografia, ressonância magnética e outros exames oferecidos corriqueiramente na data de firmatura deste contrato (...)." ↩
2. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/973316-cancer-deve-ser-a-primeira-causa-de-mortes-no-pais> ↩